第34卷第3期 河北法学 Vol. 34, No. 3
2016年3月 Hebei Law Science Mar., 2016

DOI: 10.16494/j.cnki.1002-3933.2016.03.014

从指标权交易到发展权交易
——美国TDR制度对地票制度的启示

曾 野

(西南政法大学 经济法学院,重庆 401120)

摘 要: 大洋彼岸的美国自20世纪60年代开启了土地管理的市场化路径,TDR(可移转发展权)交易制度勃兴,该制度如今更得到了世界各国的广泛认可。无独有偶,我国各地亦普遍开展了土地管理的市场化实践,这其中最为典型的是地票交易制度。虽然体制有别、环境各异,但是我国的地票交易制度与美国之TDR制度拥有相同的核心理念——将土地权利市场化,以及诸多共通之处。然而,众多非市场化的制度设计导致地票使用范围有限、市场空间狭小,而市场化又恰是美国TDR制度的优势。据此,以美国发展良好的TDR制度为鉴,为地票交易制度的完善提供理论支持,既是地票交易制度发展的可行路径,又是契合十八届三中全会"市场决定论"的理论选择。

关键词: 地票交易;TDR制度;指标权;可移转发展权

中图分类号: DF41 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-3933(2016)03-0144-11

From Index Rights Trading to Development Rights Trading
——The enlightenment of TDR system in the USA to land ticket trading system

ZENG Ye

(Economic Law School, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120 China)

Abstract: At the other side of the ocean American has used market based approach to manage land use since the twentieth Century 60's, then TDR system began to flourish, and was now accepted by countries world wide. It is not unique, market based practices of land use management were also carried out in our country, with all the practices land ticket trading system was the most typical one. Although different institution and

收稿日期: 2015-10-20 该文已由"中国知网"(www.cnki.net)2016年1月11日数字出版,全球发行

作者简介: 曾 野(1984-),男,重庆人,西南政法大学经济法专业博士研究生,云南民族大学法学院讲师,研究方向:经济法。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

environment between China and American, the land ticket trading system and TDR has the same core idea, that is making property rights market oriented, plus the two system has much more similarities. But, land ticket is used in a limited field and also has little market place to set in, mainly because many non market oriented designs, on the other hand market oriented is just the advantage of TDR system. Thus, treat the well developed TDR as a guide, and provide theoretical support for the perfection of the land ticket trading system , that is not only a feasible path of the development of the land ticket trading system, but also the theoretical choice which fit the "market determinism" of Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee.

Key words: land ticket trading system; TDR system; index rights; transferable development rights

引言

美国的 TDR(可移转发展权) 交易制度是对其分区规划(zoning) 制度的重要革新[1] ,在美国其常常被称为 "Novel planning Tool"[2] ,意为土地规划的新举措。美国的土地使用制度在世界范围内独树一帜,根植于美国人观念中的土地无限化思维深刻地影响着美国的分区规划制度[3] ,对私有财产的特别保护,是 TDR 制度发端于美国的重要原因,分区规划(zoning) 制度由于对私人财产权的侵犯,一度受到强烈的指责。为了弥补分区规划的不足,更好的在维护社会公共利益的同时保护私人利益,TDR 制度应运而生。其实,中国文化中亦有相同的思想,管制当中特别注重 "疏" 和 "堵" 相结合就是一例,分区规划 "堵" 住城市的无序化发展,通过 TDR 制度进行 "疏导"。在我国土地管制之下,各地方为了解决用地问题,纷纷求助于市场化运作予以 "疏导",这其中最为典型的是 "江浙模式" 和成渝两地的 "地票交易制度", "江浙模式" 被叫停,2011 年成都的地票交易也被叫停,但是重庆市的地票交易仍发展良好,得到广泛支持,这无疑有许多值得思考和总结之处。在我国严格的土地管制下,地票交易制度迈出了市场化的重要一步,然而地票交易制度的尝试并非完满,其中尚有许多亟待完善之处。美国的 TDR 制度与我国的地票交易制度有着诸多相似之处,且得到了世界各国的广泛认可,可为完善我国地票交易制度提供实践范例和理论支持。

一、美国 TDR 制度与地票交易制度的对比分析

地票实质是建设用地指标,取得地票就取得了在土地上进行开发建设的权利,同样土地发展权亦是一种能够在土地上进行开发建设的权利,因此地票和土地发展权之间联系紧密①。以此为基础的地票交易制度与美国的 TDR(可移转发展权交易) 制度同样存在着诸多相似之处。

(一) 制度功能的相似性

从制度的功能而言,美国的 TDR(可移转发展权交易) 制度与地票交易制度十分相似。

① 西南政法大学黄忠教授对地票法律属性的研究颇为深入,在其《地票交易的地役权属性论》一文中,黄忠教授指出 "由于在我国现行法中并无土地发展权的明确规定,因此就现行法而言,以土地发展权来解释地票交易似无理据"。黄教授赞成地票的法律属性是地役权,然而,从黄教授实然的、严格法定主义的思路出发,地票被定义为地役权也是于法无据。文中对地票与发展权的讨论更倾向于应然层面。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

土地发展权这一概念最早在英国1947年的城乡规划法中出现，但英国并没有规定土地发展权的自由交换，而是将其划归国有[4]，英国土地发展权并没有从规划制度中分离而演变成为一项独立的可交易的权利形态，土地发展权也最终在英国流产。与此不同的是，美国将土地发展权作为一项独立的可交易的财产权，并且取得了良好的效果[5]。土地发展权于1961年在纽约市的分区规划中被引入，以解决在城市发展中对历史地标(Landmarks)建筑的保护，而最早在法律中对可移转土地发展权TDRs进行详细规定的，是1968年的纽约城市地标保护法[6]。可移转的土地发展权TDR制度实际是为了解决因为严格的分区规划所带来的土地使用问题，以平衡各地块所有人之间的利益。可以说，正是因为严格的分区规划制度使得可移转土地发展权TDR制度得以产生。

无独有偶，我国的地票交易制度亦产生于我国严格的土地规划制度。在我国，土地受到严格的用途管制，国家和地方政府通过土地利用总体规划、年度建设用地规划以及控制性详细规划等，将土地的利用指标化，并逐级下放。土地用途的严格控制是为了保护耕地、集约节约用地，在《土地管理法》、《城乡规划法》的管控下，建设用地一地难求。实践中各省市无一例外的为了解决土地供需矛盾而对用途管制进行了突破，这其中以浙江模式和成渝两地的地票模式最为典型，这两种模式都是以耕地指标的动态平衡为出发点，实现建设用地开发权在空间上的位移以形成所谓的以地换地，这两种模式普遍被视为我国土地发展权移转制度的实践模型。因此，地票交易制度与美国的TDR制度具有相同的功能，均是用于弥补严格土地规划制度的不足。

(二)制度设计的相似性

在制度设计方面，美国的TDR制度与地票交易制度也十分相似，甚至许多学者认为地票交易制度就是我国发展权交易的一种制度实践①。

首先，地票与可移转发展权的内涵相同。土地发展权也是一种是否能够增加土地开发强度的权利，在美国它主要是指能够增加建筑物高度、容积率、密度等受土地规划影响的开发强度[7]。我国学者刘国臻就曾指出“所谓土地发展权，就是土地变更为不同性质使用之权，如由农地变更为城市建设用地。”[8]同样，前文述及地票是一种建设用地指标，只有在取得该指标后，才能够增加对农用地的开发强度，使之转变为建设用地。也即，取得地票，就取得了改变土地用途、增加土地开发强度的权利。足见，地票与土地发展权具有相同的内涵，权利人在取得地票或土地发展权后，均能够实现增加相应地块的开发强度的效力。

其次，TDR制度与地票交易制度均是在严格的土地管制下引入了灵活的市场机制作为激励。美国的TDR制度，由被限制发展地块的所有者，将其被限制的发展权出售给需要增加

① 具体可参见汪晖，陶然《论土地发展权转移与交易的“浙江模式”——制度起源、操作模式及其重要含义》，载《管理世界》，2009年第8期。万江《土地用途管制下的开发权交易——基于指标流转实践的分析》，载《现代法学》2012年第5期。方丽，田传浩《土地发展权转让市场机制与中国土地利用规制创新》，载《中国房地产》2012年第14期。当然，介于我国和美国土地权利结构的较大差异，以及国家体制的不同，这一论断可能缺乏合理性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

开发强度的土地所有者，交易过程中土地发展权的定价也是由市场来决定的。为了保证交易顺利完成，多个州建立起了政府主导的，利用公共资金设置的土地发展权银行作为交易平台，以解决土地发展权交易中的诸多问题。同样，重庆地票交易制度以重庆农村土地交易所作为平台，将经过整理、复垦后折算出的地票以公开竞价的方式拍卖，由市场来决定地票的交易价格。从某种程度上讲，发展权与地票是可以相互替换的概念。

再次，美国 TDR 制度与地票交易制度的运作模式也基本一致。美国的 TDR 制度是通过将土地发展权从受限制的、开发强度低的土地上，转移到不受限制的、开发强度高的土地上。开发强度低的土地通常是因为古建筑保护、农地保护、森林保护等原因被限制了发展权，为了对其权利人进行补偿，法律允许其将被限制的发展权以一定比例折算后，出售给发展权不受限制，且需要加强开发之土地的权利人。因土地发展权受限而出售发展权之地为权利的发送地(Sending Areas) ，购买土地发展权加强开发的土地称为权利的接收地(Receiving Areas) [9] 。与此相同的是，地票是通过对闲置的宅基地和农村建设用地进行整理和复垦，经过验收以后取得地票(建设用地指标) ，再将该地票售卖，买受人最终将地票用于将规划区内(通常是城市周边) 的农用地变为建设用地，即落地。这其中，被整理和复垦的宅基地和农村建设用地(一般为较偏远地区) 为地票的发送地，而落地之处的农用地(一般为城市周边) 为地票的接收地。最终，地票实现了将偏远地区农村建设用地从空间上“位移”到了城市周边，成为了城市建设用地①。

(三) 制度基础的差异性

美国 TDR 制度与地票交易制度虽然十分相似，但由于中美基本土地法律制度的差异，决定了美国 TDR 制度与地票交易制度之间也同样存在较大差异。美国的 TDR 制度建立在以美国的财产权制度为基础的土地法律制度之上，是直接创新了一种赋予土地所有人对抗严格土地分区规划的新的权利形式，该创新并不受物权法定主义的限制。同时，由于遵循的是土地私有制，美国的土地权利结构并不似我国复杂，TDR 制度在运行过程中不需要迎合多方的利益需求，各州的政府并不直接参与 TDR 交易的利益分配，真正利益交换的主体只有发展权发送方与发展权接受方。因此，美国各州的政府在参与 TDR 交易时，主要是提供服务、搭建平台，通过税收间接的实现收益，不会主动发起 TDR 交易，仅起到一个居间者的作用。TDR 交易所得收益，直接归属于交易双方，不存在多方利益主体的分配困境。

与此不同的是，我国实行的是土地的公有制，土地的所有权分属于国家和集体，私人不享有土地的所有权，仅仅能够享有土地的使用权。同时，我国的土地法律制度以《物权法》为核心，遵循严格的物权法定主义，地票很难绕开现行法律规定而设计成为一项新的权利形式。由于没有土地所有权作为基础，我国的私人想要从土地收益中分享权益比较困难，尤其

① 实际上地票并非是将偏远地区建设用地从农村换到城市周边，而是将其中的发展权进行了调换。通过土地复垦和整理换出偏远地区建设用地本来的发展权，再将其转移给城市周边没有发展权的农地之上，使这些农地获得了相应的发展权，具备了转为建设用地的可能性。农地与建设用地最大的不同，既是农地的发展权受限，只能用于农业活动开发强度低，而建设用地的发展权广泛，开发强度高。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是在农村的双层经营体制下，这一矛盾就愈发的突出和复杂。农民在承包经营土地时面临多重身份的冲突，第一，作为集体成员，他是其经营土地的共有人；第二，作为承包人，他是其经营土地的经营者和使用者；第三，作为耕种者，他还是执行国家粮食安全政策的义务人。与农民复杂的身份结构相应的是农村土地权利结构的多层次化和模糊化，尤其体现在改变土地用途（即征收）时。征收中以何种标准对农民进行补偿，中央政府、地方政府、集体和农民之间如何分享因土地用途改变所带来的增值收益，谁来代表集体以及集体的组织形式等问题一直困扰着土地实践，处理不好还常常引发群体性事件。如何在农村复杂的土地权利结构下，在严格的土地管理制度下实现土地的灵活使用，成为了各地方经济发展的首要任务。各个地方相继开始了土地利用的市场化实践，这其中具有代表性的做法就是浙江模式和成渝两地的地票，而浙江模式被叫停成都地票交易也已暂停，唯有重庆地票交易进展顺利。对此学者史晋川在分析浙江模式时指出，浙江模式之所以被中央叫停，利益分配不均衡是关键[10]。

实际上，TDR 制度是将因规划而带来的土地增值收益中，应当补偿给受规划限制的发展者的部分，通过出售土地发展权，直接分配给受限制者。而地票交易制度中，应当补偿给农民的一部分，仍然需要从地票收益中进行再分配，具体比例则是通过文件来规定①。

表 1　TDR 制度与地票交易制度的对比

类别	交易发起	交易原因	交易准备	主要第三方机构	交易程序	用途	法律	收益分配
TDR 制度	交易双方	保护土地、增加开发强度	评估、区域划定	土地发展权银行（非必要）	相对简单，不需要征收	土地发展权用途广泛	得到联邦及 28 个州的肯定	交易双方、政府税收
地票交易	地方政府	保护耕地、增加建设用地指标	复垦、折算	农村土地交易所（必要）	相对复杂，需要征收	地票用途单一，只能转换为建设用地指标	未获明确肯定	集体、农民、复垦公司、多级政府

二、市场化：地票交易制度的困境及 TDR 制度的优势

在对地票交易制度的众多质疑中②，有一类观点尤其值得关注，即地票真实的形成情况缺乏透明度，交易由政府一手主导，在整个交易过程中，农民基本置身事外，农民退地收益没有完全得到兑现[11]。可以说，这是在我国目前的复杂的土地权利结构下，地票交易必然面临

① 例如，重庆市国土房管局制定的《关于规范地票价款使用促进农村集体建设用地复垦的指导意见（试行）》第 3 条第（七）项规定，“……确保复垦宅基地及其附属设施用地的地票平均价款扣除复垦项目工程成本和融资成本后，85% 支付给该区县（自治县）退出宅基地的农户，平均费用每亩不低于 9.6 万元……”

② 具体可参见冯桂《重庆地票制度的价值及其对城乡一体化改革的启示》，载《国家行政学院学报》，2014 年第 1 期，第 81－82 页。在该文中，冯桂将学界对地票交易的各种批评和质疑进行了全面的梳理。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的难题。在市场化方面，地票交易制度仅迈出了十分谨慎的一小步，而美国的TDR制度则是完全的以市场为导向(Market-Oriented)，地票交易的困境正是市场化的困境，这也恰恰是美国TDR制度能够被世界各国所认可的优势。

(一)地票交易市场:国家垄断的土地一级市场

虽然在对地票定价时，地票交易制度引入了市场机制，但是总体而言，地票交易市场仍然是国家垄断的土地一级市场。出于保护耕地、合理利用土地的考虑，国家严格限制农用地转为建设用地，垄断并控制着土地的“一级市场”。地票交易制度虽然在严格的土地管制下有所创新，但地票交易市场仍然是国家所垄断的土地一级市场。通过复垦和整理，经过验收后，地票产生并登记在农村土地交易所进行组合挂牌交易。交易完成后，地票收益按照文件规定进行分配，而地票的持有人(购买方)尚无法直接使用，地票还需要落地，所谓落地即是持有人再通过“招拍挂”取得建设用地使用权，两种指标合并才能够实现对土地的开发利用。地票的落地过程，仍然需要依靠对农用地进行征收，将农用地转为建设用地，本质上，地票交易还是土地一级市场上的交易。要使地票制度进一步市场化，首先就要开放地票的一级市场。

与地票交易制度形成较大反差的是，美国的TDR制度是在充分的市场机制下进行的。不仅发展权转移的发起者是土地所有权人，而且发展权的转移和使用并未受到国家和州政府太多的限制，只要符合分区规划的需要即可。发展权的用途多样，既可以用于增加开发强度，又可以自由转让、抵押进行融资，政府还通过出资发展权银行，将购买的发展权进行储存和销售，以解决部分出售方和购买方之间的信息不对称难题。同时，政府并不限制土地所有权人一定将发展权售卖给政府，发展权的交易遵循自愿、平等的原则。在这种情况下，地票出卖人和地票的购买人双方均实现了福利的增长，且是自由的完成了交易，政府则通过税收和相关费用的收取亦实现了福利的增长。通过市场化的土地发展权移转，分区规划所带来的不公平问题得到解决，各方实现了福利的帕累托改进。

(二)地票权益分享:多方博弈的复杂结构

地票交易非市场化的另一表现是复杂的地票权益结构。一张地票，不仅承载着失去宅基地农民的居住权益，还承载着集体的所有权益、各级地方政府的增值收益分配权、国家对土地的增值收益分配权甚至负责土地整理、复垦公司的报酬请求权。在如此复杂的结构之下，地票各方的权益很难得到完全的实现，各方在地票中进行着博弈。有文章就指出，重庆市文件规定了具体分配数额，以及明确要以三农为重，只是规定是好的，确实为农民着想，但具体操作中市政府保存多少，区县政府下设的公司扣除多少，村集体截流多少，目前仍处于灰色地带，不够公开、透明，缺乏有效监管[12]。

美国TDR制度在利益分配方面就更加的清晰和透明:首先，TDR制度的决策更加透明，整个计划由所有利益相关者参加，这能避免决策武断的冲动，有助于促进决策科学化[13]；其次，交易双方的利益是由发展权的供需关系来决定的，当然政府所管理的评估机构会计算出发展权的基本参考价格，一般是通过最低价格和最高价格来划定一个范围。然而，政府所要

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

做的工作远不止此，在确定交易价格区间之前，政府还通过划分最小地块面积(minimum lot size) [14] ，来确定发展权交易的最小单位面积; 其次，美国各州政府对土地的合法利益并不必然通过发展权买卖来直接实现，而是通过间接的方式来实现。例如，通过对发展权交易征税，对交易的各个环节征收相应的费用; 最后，为了解决发展权交易当中存在的困难，比如发展权作为一种抽象的权利如何来进行储存，交易当中的供给和需求常常不能在同一时间满足，交易双方信息不对称，交易所需要的技术性较强等问题，在政府的支持下美国多个州成立了土地发展权银行，通过土地发展权银行来调控土地发展权市场。当然，土地发展权银行仅是土地发展权交易的中间方，其作用类似于农村土地交易所，而其经营范围则更为广泛，但在发展权交易中，土地发展权银行主要是进行服务，并不以赢利为首要目的。

(三) 地票的使用: 缺乏灵活性的单一途径

与美国 TDR 制度相比，地票交易制度在对地票的使用时缺乏灵活性，这也限制了地票交易制度的进一步市场化。地票的使用——落地，被限定在了将农用地转为建设用地这一单一用途上，而这一用途又必须依靠土地征收来完成。因此，地票设计者希望实现的不以土地征收为必要程序的制度创新，是无法实现的。受此限制，地票交易被限定在了一个狭窄的范围内，地票交易的市场亦十分有限。而美国的 TDR 制度对土地发展权的应用就更加的灵活，土地发展权交易的市场也更加的广泛。土地发展权，代表着是否可以增加对土地的开发强度的权利，这种开发强度包括了对建筑高度的增加、对容积率(floor to area ratio) 的增加、对建筑密度(density) 的增加以及对塔投影面积(tower coverage) 的增加和改变土地的用途等多个方面。土地发展权的购买方，可以根据自己的需要来使用所购买的土地发展权，当然，前提是符合所在地区的分区规划的要求①。由于用途广泛，土地发展权交易市场的规模较大，TDR 制度所能实现的目标也就更为广泛。例如，通过交易土地发展权，给予土地发展受限制方补偿，TDR 制度可以实现对农用地的保护、对森林的保护、对古建筑的保护以及对地标建筑的保护 [15] 。同时，土地发展权的购买者则可以通过交易，实现对本地块的加强改造。另外，在美国，购买土地发展权的人并不需要改变土地原来的用途，也即完全可以通过避免征收而使用土地发展权，而我国的地票在使用的过程中则无法摆脱土地征收的限制。显然，美国的土地发展权交易市场受到的限制更小，能够发展成为具有较大规模的市场，而我国的地票交易市场自制度设计之初就受到了限制，使其不可能发展成为较大规模的交易市场。

三、以美国 TDR 制度为鉴对地票交易制度的完善

前文已述及，我国地票交易制度的主要问题是市场化的问题，党的十八届三中全会决定指出: 要“建立城乡统一的建设用地市场。在符合规划和用途管制前提下，允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股，实行与国有土地同等入市、同权同价。缩小征地范围，规范征地程序，完善对被征地农民合理、规范、多元保障机制。”，足见我国将着力逐步打破一直以

① 这种使用可以使建设一个车库，或是增加建筑物高度，也可以根据需要增设一个仓库等等。可参见 Nelson，Pruetz，Woodruff “TDR HANDBOOK Designing and Implementing Transfer of Development Rights Programs”，Island Press 2011，Foreword xvii.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

来由国家垄断土地一级市场的局面，通过市场化的手段来解决目前的土地问题。地票交易制度是在十八界三中全会重要决定之前的一次大胆的、成功的市场化尝试，但其仅仅是迈出了谨慎的一小步，需要以十八界三中全会重要决定为指导，更深入的进行市场化改革，而可资借鉴的成功范例就是美国的 TDR 制度。

（一）开放地票交易市场

有诸多讨论对地票交易的“二级市场”开放持肯定态度①，但此处所指“开放”与学者们的讨论涵义不同。如前文所述，开放所指是由市场来决定，据此，地票交易的一级市场也远未达到开放之要求，地票交易市场化的第一步就是要开放地票交易的一级市场。首先，在美国 TDR 制度中，发展权直接归属于土地发展受到限制的所有权人，是对他们的一种直接的补偿，其补偿的基础是对所有权的限制。我国目前也正在着手开放土地一级市场，集体经济组织同样能够作为土地一级市场的供应方。当土地一级市场开放后，规划范围内的集体建设用地即可直接入市进行交易，所得由集体经济组织通过其成员协商分配，而未在规划范围内的集体建设用地的开发权利将受到限制，这也为借鉴美国 TDR 制度的补偿机制提供了政策支持。在土地一级市场开放的背景下，被限制用途的集体建设用地的所有权人——集体经济组织，完全可以通过直接出售地票而获得补偿，也即地票一级市场也应当随之开放，让农民直接分享土地的增值收益。地票交易项目的发起者，应当是集体经济组织或者其成员，而不是政府，当然，集体经济组织可以委托由政府成立的土地开发公司或者其他的机构来开展整理、复垦乃至地票的出售工作，政府和其他机构应当扮演中间人的角色。在一级市场开放的背景下，地票二级市场的交易也应当同时开放。

（二）缩短地票的利益链条

地票交易市场化除了需要开放一级市场外，地票利益链条的缩短亦具有必要性。现阶段的地票交易主要是利用了农村的集体建设用地，将集体建设用地的指标通过复垦、整理等置换出地票，实际上是对农村的集体建设用地的开发权进行了限制，使之成为被保护的土地。对于集体而言，其所有的财产因为复垦、整理而减损了价值，理应获得相应的补偿。而另一方面，地票通过交易，可以使取得地票的权利人将农用地改变为建设用地，也即增加了其开发土地的权利，使其能够实现土地的增值。由是，通过地票交易，取得地票的一方理应支付相应的对价，以补偿出让地票的一方。然而，地票交易的价值却还需要分配给各级地方政府，以及参与地票复垦、整理的企业，一张地票承载着多方的利益。在我国农村双层经营的体制下，地票在集体与集体经济组织成员间的分配就是一大难题，再加上国家、各级政府和相关企业，虽有政府文件的明确规定，也很难实现地票收益的合理分配，更难实现对集体及其成员的充分补偿。当然，国家以及各级政府分享地票收益本身具有其合理性，因为地票收益的最终实现还在于落地环节，这一环节使得接受地票的土地实现了大幅的增值，最终价值减损和价值增加通过地票实现了交换。据此，地票的价值最终体现在了土地的增值收益上，孙中山曾言：“地价高涨，是由于社会改良和工商进步。……这种进步和改良的功劳，还

① 具体可参见马智利，陈锋，马敏达在《重庆地票二级市场的开放与交易机制研究》一文中的概括。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是由众人的力量经营而来的;所以由这种改良和进步之后,所涨高的地价,应该归之大众,不应该归之私人所有。”[16] 由是国家以及地方各级政府代表公共利益,从而分享地票收益具有其正当性,但其合理性值得考量。

上文论及,地票收益的过长利益链条导致多方在分配收益中难以平衡,地票权益(土地发展权)涉及国家、土地所有权人和使用权人之间的利益分配。美国的 TDR 制度较好的解决了这一难题,通过将私人所享有的一定比例的增值收益以土地发展权的形式划归私人,并通过市场机制来决定土地发展权的价格,而国家则通过土地发展银行买卖发展权的差价以及税收等形式取得另外一部分增值收益,各方在土地发展权移转交易中的利益得到平衡。美国的 TDR 制度并未让土地发展权承载全部的土地增值利益,而是仅以其负担对私人财产价值减损的补偿这一部分,在缩短利益链条的同时,政府亦能通过间接的税收和发展权银行的买卖来取得另一部分土地增值收益。借鉴美国的 TDR 制度缩短地票的利益链条,不仅可以使农民直接面对市场,真正自主来决定和发起地票交易,还能够保证土地发展利益受到损失的农民通过地票交易获得充分补偿,更进一步也能使政府通过间接的税收、收费成立中介机构等手段来获取维护社会公共利益的资金。

(三)扩大地票的用途

地票用途的扩大是一个法律问题,也同样是一个理念问题。由于对土地的严格控制,我国的个人和单位欲在土地上进行建设必须使用建设用地①,也即我国的土地从用途上划分为了建设用地与非建设用地。建设用地又可分为国有建设用地与集体建设用地,集体建设用地包括了宅基地和用于乡(镇)村公共设施和公益事业建设的集体土地。从用途管制的角度而言,建设用地比非建设用地的用途更广,而同样是用于建设,国有建设用地的用途显然比集体建设用地更加广泛。另,建设用地又可以根据不同用途划分为居住用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、交通设施用地、公用设施用地、绿地②。我国以《土地管理法》、《城乡规划法》为代表的法律、法规重在对土地用途进行划分,以区别不同的土地采取严格的分类管理,但实际上各种不同类型土地在使用过程中,真正的区别来自于开发强度的不同。例如,建设用地的开发强度远大于非建设用地,国有建设用地能实现的开发强度又比集体建设用地更大,居住用地与工业用地的开放强度也不相同。根据《城乡规划法》第 38 条的规定,土地开发强度主要是由控制性详细规划来确定③,而开发强度的具体所指主要包括地块的建筑密度、建筑高度、容积率、绿地率、基础设施和公共服务设施要求等④。在编制土地规划时,建筑密度、建筑高度、容积率、绿地率等成为了重要考

① 《土地管理法》第 43 条。

② 2012 年《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137—2011。

③ 《城乡规划法》第 38 条第 1 款,在城市、镇规划区内以出让方式提供国有土地使用权的,在国有土地使用权出让前,城市、县人民政府城乡规划主管部门应当依据控制性详细规划,提出出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件,作为国有土地使用权出让合同的组成部分。未确定规划条件的地块,不得出让国有土地使用权。

④ 《城市规划编制办法》(中华人民共和国建设部令第 146 号),第 41 条、第 42 条。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

量，也成为了对土地利用的空间限制的主要方面。申言之，我国不同用途的土地在实际利用时的差别，主要体现在了其能够达到的建筑密度、建筑高度、容积率、绿地率等方面的不同。例如，《重庆市农村村民住宅规划建设管理暂行办法》就明确规定，农村村民住宅建设原则上不得超过3层，《海南省村庄规划编制技术导则（试行）》同样规定农村房屋不应超过3层[17]。要将农用地转为建设用地，实则是要对地块的开发强度进行改变，即改变土地的建筑密度、建筑高度、容积率、绿地率等内容，地票作为建设用地指标自然应当包含上述内容。据此，地票的用途应当十分广泛，不仅可以改变农用地的建设用途，而且可以使建筑高度低的集体建设用地改变为建筑高度较高的城市建设用地，可以使容积率较低的工业仓储用地改变为容积率高的居民用地，但是地票交易制度在对地票的使用进行设计时，仅仅将地票用于了农用地转为建设用地这一单一用途，大大限制了地票的市场活力。对此，美国的TDR制度的设计值得借鉴，例如美国的马萨诸塞州将可以移转发展权简化设计成了密度信用（density credits）[18]，可移转发展权的购买者可以将发展权用于增加建筑高度、建筑密度、容积率等多个方面，以满足自身的需求，这样不仅扩大了土地发展权的需求量，也使得更多的土地发展权受限制方得到补偿，是典型的双赢的设计。因此，地票的应用可以更加的广泛，在我国这更具有实际价值，当地票的用途更加多样化后，征收这一改变土地用途的必经程序才能得到有效的控制。

结语

地票交易制度是我国土地制度的一次大胆尝试，然而其仍然是蹒跚前行，遇有诸多阻力。地票交易的本质仍然是一种指标权交易，但应然状态下的地票交易当更趋近于可移转发展权交易。在我国一直以来土地强管制的背景下，地票交易无法完全独善其身，其交易受到限制太多。十八届三中全会提出了“市场决定论”，要求市场在资源配置中起决定性作用，这无疑为土地市场的发展提供了契机，地票交易亦当更进一步市场化。发端于美国的TDR制度之所以被广泛接受，其核心在于更加市场化的制度设计，这为地票交易制度的完善提供了可行的理论选择。当然，本文的探讨仅仅是一次尝试，地票交易制度与TDR制度毕竟产生于中、美两国不同的政治、经济、人文环境之中，绝无照搬TDR制度的可能性，譬如TDR制度的发展是“城市包围农村”的过程，而我国的地票交易则是典型的“农村包围城市”的过程①。同时，TDR制度本身在实践中也有不少困难亟待解决，诸如对工作人员技术要求高、发展权储存不足、交易时间不可控等问题[19]，这都要求我国在借鉴TDR制度时考虑实际、去粗存精，而绝非简单的全盘移植。然而，要真正做到上述要求，首先要更加深入地研究TDR制度，要建立在对TDR制度有精确把握的前提之下，但目前我国理论界和实务界在这一方面的研究还仍然匮乏，本文的讨论亦可谓抛砖引玉，期望引起更多的关注。

① 美国TDR制度最初建立是为了解决城市土地的无序化发展，而后开始关涉农村土地发展问题。我国的地票交易则是为了解决农村土地流转问题，目前尚未有运用到城市建设的迹象，但未来在城市建设中的运用是可能选择。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献:

[1] Sonia A. Hirt. ZONED IN THE USA The Origins and Implications of American Land-Use Regulation [M]. Cornell University Press ,2014. 47.

[2] Nelson, Pruetz, Woodruff. TDR HANDBOOK Designing and Implementing Transfer of Development Rights Programs [M]. Island Press ,2011. xix.

[3] Sonia A. Hirt. ZONED IN THE USA The Origins and Implications of American Land-Use Regulation [M]. Cornell University Press ,2014. 27.

[4] 刘国臻. 论英国土地发展权制度及其对我国的启示 [J]. 法学评论,2008,(4).

[5] 胡兰玲. 土地发展权论 [J]. 河北法学,2002,(2).

[6] SARAH J. STEVENSON, BANKING ON TDRS. THE GOVERNMENT'S ROLE AS BANKER OF TRANSFERABLE DEVELOPMENT RIGHTS [J]. N. Y. U. L. Rev. 1998,(Vol. 73).

[7] Jennifer Frankel. Past, Present, And Future Constitutional Challenges To Transferable Development Rights [J]. Washington Law Review,1999,(Vol. 74).

[8] 刘国臻. 论美国的土地发展权制度及其对我国的启示 [J]. 法学评论,2007,(3).

[9] DENSITY TRANSFER CREDIT. INNOVATIVE LAND USE PLANNING TECHNIQUES: A HANDBOOK FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT [EB/OL]. www. des. nh. gov/organization/divisions/8 water/wmb/repp,2015-05-11.

[10] 史晋川. 为什么有效的制度会被叫停? ——关于《论土地开发权转移与交易的"浙江模式"》的评论 [A]. 张曙光. 中国制度变迁的案例研究(土地卷)第八集 [C]. 北京: 中国财政经济出版社,2011. 170.

[11] 杨仕省,高咏梅. 重庆地票制度漏洞开始浮现 [N]. 华夏时报,2012-03-31.

[12] 姚佳威. 重庆地票继续试行,农民反响不一 [EB/OL]. http://finance. sina. com. cn/china/dfjj/20110117/18099266646. shtml,2014-11-10.

[13] 魏建新. 论利益相关方参与行政决策 [J]. 河北法学,2014,(6).

[14] David P. Ernstes, Dawne M. Hicks. Increasing Understanding of Public Problems and Policies——1998 [J]. Farm Foundation,1999,(February).

[15] Brabec, E., C. Smith. Agricultural Land Fragmentation: The Spatial Effects of Three Land Protection Strategies in the Eastern United States [J]. Landscape and Urban Planning ,2002,(58).

[16] 陈柏峰. 土地发展权的理论基础与制度前景 [J]. 法学研究,2012,(4).

[17] 万江. 土地用途管制下的开发权交易——基于指标流转实践的分析 [J]. 现代法学,2012,(5).

[18] Transfer of Development Rights (TDR) [EB/OL]. http://www. mass. gov/envir/smart_growth_toolkit/pages/mod - tdr. html,2015-03-20.

[19] TWilliam Fulton, Jan Mazurek, Rick Pruetz, Chris Williamson. DRS AND OTHER MARKET - BASED LAND MECHANISMS: HOW THEY WORK AND THEIR ROLE IN SHAPING METROPOLITAN GROWTH [J]. The Brookings Institution Center on Urban and Metropolitan Policy,2004,(June).

(全文共15,433字)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net